

1501345-05.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... na exordial acusatória, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, restaram devidamente comprovados. Na data aludida, o acusado determinado a praticar o tráfico de drogas se apoderou de dezenas de porções contendo "maconha" e cocaína, em uma sacola plástica, e dirigiu-se até a via pública, local conhecido por ser ponto de venda, próximo a um córrego e ao estabelecimento de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501345-05.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501345-05.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142974/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 25193310 - 01º D.P.

GUARULHOS, 2142974 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DE CASTRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glaucio Roberto Brittes de Araujo

VISTOS.

GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DE CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 333, caput do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 25 de maio de 2022, por volta das

16h, na Rua Diamantina, altura do nº 96, Bairro Macedo, nesta cidade e comarca de Guarulhos, nas imediações do estabelecimento de ensino "Colégio Parthenon - Unidade I", trazia consigo, para fins de tráfico, 54 porções contendo 24,3g de cocaína e 39 porções contendo 80,04g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11/12, croqui a fls. 10, mapa ora anexado e laudo de constatação provisória contendo fotografias a fls. 14/18. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício.

A denúncia foi oferecida. O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação. A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha comum à acusação e defesa, seguindo-se o interrogatório do acusado.

Superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, postulou fixação da pena base acima do mínimo legal, ante a quantidade e natureza das drogas, regime fechado, sem substituição por restritiva de direitos.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, atenuante da confissão espontânea, aplicação do redutor do privilégio, afastamento da causa de aumento de pena previsto no inciso III, do artigo 40 da Lei 11343/06, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da absolvição em relação ao delito previsto no artigo 333 do CP, nos termos do artigo 386, VII do CPP.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisória, pelo laudo do exame químico-toxicológico definitivo, pelo croqui, pelo mapa do local e pela prova oral a seguir examinada. A esqualidez do complexo probatório do crime de corrupção ativa, contudo, não autoriza condenação.

A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento das drogas, a quantia em dinheiro apreendida R\$ 223,00 (fls. 11/12), a confissão e as circunstâncias da posse evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente indubitosa, considerando todo o conjunto probatório.

O réu confessou a prática do tráfico, admitindo que as drogas lhe pertenciam e que usa apenas maconha, mas tem conseguido ficar sem o consumo da substância. Declarou trabalho em domicílio. Negou ter oferecido alguma vantagem para os policiais. A confissão encontrou sólido respaldo probatório, enquanto a ressalva (negativa) sobre a corrupção ativa não foi infirmada em juízo. Vejamos.

O policial Diego afirmou que, em uma conhecida biqueira, avistaram um réu e outro indivíduo caminhando. Inicialmente pensaram que eles iriam adquirir entorpecentes, mas repentinamente o réu foi até um portão à esquerda e recolheu uma sacola do

interior do imóvel. Na tentativa de abordá-lo, o outro indivíduo se evadiu. Na sacola havia entorpecentes. O réu também tinha dinheiro fracionado. Ele tentou se evadir, impedindo a colocação de algemas, razão pela qual feriu a mão do seu parceiro. Aduziu que ele ainda tentou fugir na viatura. Chegou a mencionar algo sobre a família para não ser preso. Não se recordou de uma vantagem específica supostamente oferecida pelo réu.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, restaram devidamente comprovados. Na data aludida, o acusado determinado a praticar o tráfico de drogas se apoderou de dezenas de porções contendo “maconha” e cocaína, em uma sacola plástica, e dirigiu-se até a via pública, local conhecido por ser ponto de venda, próximo a um córrego e ao estabelecimento de ensino “Colégio Parthenon – Unidade I”, onde passou a exercer a traficância. Ocorre que, em diligências para combater o tráfico de drogas na região, policiais o surpreenderam em atitude suspeita e na posse da referida sacola, além de dinheiro trocado. Ainda confessou a realização da atividade ilícita.

Com efeito, observa-se que a confissão judicial encontrou sólido amparo nas provas produzidas. Não permaneceu isolada e foi corroborada por várias declarações. Nenhum dado concreto a abalou. Não há que se falar, portanto, em eventual insuficiência, por seu valor relativo, da confissão judicial, já que esta, no caso dos autos, está amparada por vários elementos probatórios, mormente depoimentos harmônicos. Nesse sentido, transcreve-se lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(..) a confissão ganha qualquer outra prova. Até certo ponto ela as transcende; elemento no cálculo da verdade, ela é também o ato pelo qual o acusado aceita a acusação e reconhece que esta é bem fundamentada; transforma uma afirmação feita se ele em uma afirmação voluntária. Pela confissão, o próprio acusado toma lugar no ritual de produção da verdade penal”. (Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: RT, 2012, p. 470).

A propósito, no caso em apreço, os testemunhos, inclusive no inquérito, atestaram, em uníssono, com detalhes, coerência e firmeza, a posse das drogas pelo réu em situação de manuseio e vendas, revelando plena adesão ao tráfico, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa convincente e não cogitou de motivo para ser supostamente incriminado falsamente. Não é crível, outrossim, que aquela quantidade de maconha e cocaína se destinaria apenas ao uso pessoal, sobretudo em local público e em porções. Assim, não obstante os argumentos da Defesa, as provas da dinâmica dos fatos exposta na exordial são fartas, restando indubitáveis autoria e dolo.

Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal, inclusive sobre a reação sintomática. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS.

POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida – 24 (vinte e quatro) invólucros com crack – revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

E o decreto condenatório não se baseia tão somente na palavra de policial, confissão ou nos dados do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial sobre a dinâmica da obtenção dos elementos sensíveis da infração, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

“(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto”. (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

Nesse sentido, o relato do policial, sob o contraditório, deve prevalecer sobre a impugnação genérica da defesa, pois foi coerente nas duas fases processuais, minucioso, harmônico, seguro e condizente com os elementos sensíveis da infração. Não havia motivos, a propósito, para incriminar falsamente um desconhecido. Também não surgiram indícios de que a droga pertencesse a outrem ou de equívoco no flagrante.

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento da droga, a quantia em dinheiro apreendida, a confissão espontânea e as circunstâncias da ação revelaram sobejamente a destinação a terceiros. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei. O acusado é imputável e praticou os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica ou de vício, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não autorizam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

No mais, restou comprovado que a mercancia era realizada perto de estabelecimento de ensino. Com efeito, o acusado foi flagrado nas imediações da Colégio Parthenon – Unidade I, conforme croqui e mapa (fls. 10 e 66). Assim, presente o risco condizente com a aplicação da causa de aumento, tendo em vista o acesso fácil dos estudantes e menores às drogas. Embora a norma não exija horário de aula ou venda direta a aluno, é certo que a ocorrência se deu em período vespertino (por volta das 16 horas), em que há movimento ou acesso à escola. De qualquer modo, o tipo prescinde da proximidade de menores ou outro fator específico, contentando-se com o perigo, como fruto do recurso comum à técnica legislativa de tal jaez.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Por outro giro, não há de se reconhecer pratica do crime de corrupção ativa, uma vez que o policial ouvido em juízo nada mencionou sobre proposta efetivada pelo acusado e não esclareceu em quais circunstâncias teria ocorrido, de sorte a permitir ao julgador a compreensão integral dos fatos e do sentido de eventual discussão entre os envolvidos sobre a prisão. Insuficiente referência vaga exclusivamente no inquérito, nos termos do art. 155, CPP. Assim, a negativa do interrogatório não foi cabalmente rechaçada pelo resultado da instrução.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena, fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito de tráfico.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a primariedade técnica do acusado (fls. 29/31). A quantidade já é considerada na configuração da destinação a terceiros e no emprego de redução menor na terceira fase, não sendo usada aqui para majoração, sob pena de bis in idem.

Na segunda fase, resta prejudicada a atenuante da confissão espontânea, haja vista a impossibilidade de redução da pena aquém no mínimo legal.

Na terceira etapa, incide a causa de aumento (inciso III, artigo 40 da Lei 11.343/06), justificando-se majoração em 1/6 da pena, que resulta em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de prova de envolvimento em organização ou dedicação à atividade criminosa, adota-se a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/3, totalizando 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão além de 388 dias-multa. Com efeito, não há prova suficiente de dedicação ao tráfico. Não foram apreendidas anotações vetustas das vendas, não houve confissão – nem mesmo informal – da realização há algum tempo daquelas e não foram encetadas diligências exitosas sobre o vínculo permanente do réu com a criminalidade. Sob o crivo do contraditório, não se demonstrou, de maneira inequívoca, a dedicação atual à atividade criminosa, mormente tráfico, que o distinguisse do traficante iniciante ou “de primeira viagem”. Para tanto não basta a quantidade, conforme vasta jurisprudência dos tribunais superiores.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despiciendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz

para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase.

Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade e a natureza de parte da droga, não se exige a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador. A propósito, a lei estabelece somente que as penas “poderão” ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução como simples benefício – que já pode ir aquém do mínimo legal – e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica das normas sobre a matéria, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto e a especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva. Ausente prova de efetivo comando e gerência na região, por outro lado, descabida a redução mínima da sanção.

Assim, para a pena definitiva de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, cabe o regime inicial aberto para o cumprimento, tendo em vista ainda o “privilégio”, a natureza do crime (sem violência ou ameaça que poderia exigir o fechado) e as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena, sem prejuízo da possibilidade de outro mais gravoso (aqui aberto) em razão de fatores específicos, ausentes no caso concreto. Sobre a temática, confira-se:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE”. (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Preenchidos, por conseguinte, os requisitos do art. 44 do CP, à luz da pena aplicada e da primariedade, sendo ainda socialmente recomendável, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena a uma entidade com função social, e prestação pecuniária de um salário-mínimo especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Órgão Ministerial para CONDENAR o réu

GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES DE CASTRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inc. III, c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, na pena privativa de liberdade de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, substituída por prestação gratuita de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade com função social, em condições especificadas na execução, além de 388 dias-multa pelo valor unitário mínimo, e para ABSOLVÊ-LO da imputação do artigo 333, "caput", do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal .

O réu poderá apelar em liberdade, pois concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura Clausulado, em favor do acusado. Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro o perdimento do dinheiro em favor da União, ante as evidências do liame com o tráfico, e determino a incineração da droga apreendida.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado, observada a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 18 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito

Glaucio Roberto Brittes de Araujo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA